

1500749-91.2020.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016 - grifei).

Assim, mesmo sem mandado judicial, tratando-se o crime de guarda de armamento permanente, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500749-91.2020.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2142214/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 11845314 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1839/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2142214 - 03º D.P. PIRACICABA, 1839/20/922 - 03º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO APARECIDO DE FRANCA

Vítima:

A COLETIVIDADE

Artigo da Denúncia:

*

Aos 01 dias do mês de fevereiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentadas as testemunhas arroladas em comum pelas partes : Gabriel Camilo Ribeiro e Thiago de Campo.

Ausente o acusado Marcelo Aparecido de França, o qual foi devidamente intimado (fls.111) e não compareceu nem virtual e nem presencialmente.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Thiago) pelo sistema virtual. Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Gabriel. Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que o réu foi devidamente intimado e não compareceu nem virtual e nem presencialmente, DECRETO A SUA REVELIA.

Homologo a desistência das partes em relação á testemunha Gabriel Camilo Ribeiro. "Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, MARCELO APARECIDO DE FRANCA está sendo processado como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Feito processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos do inquérito que, no dia 11 de junho de 2020, por volta das 04h30min, na Avenida Raposo Tavares, número 1556, Bairro Vila Cristina, nesta cidade e comarca, MARCELO APARECIDO DE FRANCA, qualificado e indiciado a fls. 05/06 e 13, possuía e matinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) espingarda sem marca aparente, numeração ilegível, calibre .28, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, o denunciado mantinha no interior de sua residência a arma de fogo acima descrita. Ocorre que policiais militares se deslocaram ao endereço para atenderem uma ocorrência versando sobre violência doméstica. Via COPOM, foram informados sobre a posse irregular da arma de fogo. Indagado pelos policiais, o denunciado confirmou que possuía a arma no interior da sua residência, a qual foi apreendida por não possuir qualquer documentação (auto de fls. 10 e laudo pericial de fls. 57/60). Na delegacia, permaneceu silente (fls. 05).

DA PROVA EM JUÍZO

Thiago de Campo - Policial Militar- confirmou os fatos descritos na inicial. Disse que foi atender a uma notícia de violência doméstica. Ao bater na casa, conversou com o réu. Quando estava no local, recebeu a notícia que ele teria uma arma de fogo. Ele assumiu que tinha e que estava sobre o guarda-roupa. Era uma espingarda antiga que tinha sido do pai dele. Não tinha munição na arma nem na casa.

No mesmo sentido, Gabriel Camilo Ribeiro, PM, quando ouvido na fase policial.

Réu revel.

NÃO HÁ DÚVIDAS

O denunciado mantinha no interior de sua residência a arma de fogo sem qualquer documento que o autorizasse.

O fato de a arma estar desmuniada não afasta o delito, posto que se trata de perigo de delito abstrato e o laudo comprovou que a arma era eficaz para disparos. Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL Estatuto do Desarmamento art. 14 "caput", da lei 10.826/03 Réu que portava arma de fogo desprovido de autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar - Pleito de absolvição - Atipicidade da conduta pelo fato da arma estar desmuniada Inadmissibilidade Crime de perigo abstrato Delito de porte de arma de fogo se trata de um delito de mera conduta, ou seja, que exige apenas o enquadramento da prática em um dos verbos previstos no tipo penal para sua consumação, sem maiores digressões ao fato de a arma estar ou não municiada Alteração da pena restritiva de direito para prestação de serviço à comunidade Descabimento - Sentença mantida - Recurso improvido."(TJ/SP, 0002966-12.2009.8.26.0101 Apelação, Relator(a): Camilo Léllis, Comarca: Caçapava, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/10/2012, Data de registro: 31/10/2012).

DA PENA

Folha de antecedentes e respectivas certidões às fls. 63/70: MARCELO é portador de maus antecedentes (ostenta condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo) e ainda possui condenação recente pela prática da contravenção penal do art. 50 da LCP (1542373-50.2018.8.26.0451).

Regime aberto (Súmula 269 STJ).

Nada impede a substituição por restritiva de direitos.

PEDIDO FINAL

Pela procedência da ação nos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Marcelo Aparecido de Franca foi denunciado como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Segundo a denúncia (fls. 75-76), no dia 11 de junho de 2020, por volta das 04h30, na avenida Raposo Tavares, número 1556, bairro Vila Cristina, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Marcelo possuía e matinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) espingarda sem marca aparente, numeração ilegível, calibre .28, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, o réu mantinha no interior de sua residência a arma de fogo acima descrita. Ocorre que policiais militares se deslocaram ao endereço para atenderem uma ocorrência versando sobre violência doméstica. Via COPOM, foram informados sobre a posse irregular da arma de fogo. Indagado pelos policiais, o réu confirmou que possuía a arma no interior da sua residência, a qual foi apreendida por não possuir qualquer documentação (auto de fls. 10 e laudo pericial de fls. 57/60).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 5-6).

Em solo policial, Gabriel Camilo Ribeiro, policial militar, narrou que: "por volta das 04:30 horas do dia de hoje estava, juntamente com seu colega De Campo, desempenhando sua função de policial militar. Foram acionados pelo COPOM para se dirigirem ao local dos fatos, para atenderem ocorrência de violência doméstica. No local, o depoente e seu parceiro fizeram contato com o casal, que informou que houve uma discussão anteriormente, porém, já tinham resolvido e não queriam registrar a ocorrência. Enquanto conversavam com o casal, o COPOM informou que, segundo denúncia, havia uma arma de fogo na residência. Indagado, o indiciado afirmou que possuía uma espingarda, que estava sobre os guarda-roupas, franqueando a entrada do depoente e seu colega, que a localizaram no local indiciado, tratando-se de uma espingarda, calibre 28, sem munição, sem marca aparente, com numeração, porém, ilegível. O proprietário afirmou que a arma pertencia ao seu genitor, que faleceu no ano passado e que não possui registro dela. Deu voz de prisão ao sujeito e o conduziram a esta delegacia" (fls. 3).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Thiago de Campo (fls. 4).

Às fls. 63-65, certidão de objeto e pé que indica os maus antecedentes do requerido (autos n.º 0016723-61.2007.8.26.0451 – trânsito em julgado em 26/8/2008).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo de fls. 57-60.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, foi ouvido Thiago de Campo, policial militar. Relatou que recebeu chamado do COPOM informando que um indivíduo estava agredindo a esposa. Chegaram no local, entraram e foram até a laje. Bateram à porta. Todos estavam dormindo e a briga já tinha acabado. Quando estavam no local, o COPOM informou que havia uma arma de fogo no local. Parece que a enteada estava passando essas informações. Perguntado, ele confirmou que tinha a arma e estava em cima do guarda-roupa. Estava embrulhada em um tecido e desmuniada. Era uma espingarda .28 antiga que o réu explicou que pertencia ao pai. O irmão, dependente químico, já tinha vendido uma espingarda de pressão e, para que não vendesse essa também, levou para casa por ser recordação do pai. O pai já havia falecido. A enteada não morava na casa, somente um filho mais novo. O réu foi tranquilo, não foi necessário usar algemas. Perguntado, disse que falou ao réu que era direito dele não permitir a entrada na casa, mas ele os convidou e ainda foi o responsável por tirar a arma de cima do guarda-roupas.

O réu é revel.

- DA NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA A PARTIR DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO

Preliminarmente, deve-se reconhecer a ilicitude de toda prova produzida a partir do

ingresso dos policiais no domicílio do acusado, eis que a entrada no local se deu com violação ao princípio constitucional que assegura a inviolabilidade do domicílio. Isso porque não há prova nos autos de que houve consentimento de pessoa que ali residia para ingresso no local.

Considerada a essencialidade da proteção ao domicílio para a garantia da tranquilidade e bem-estar dos indivíduos, as hipóteses em que agentes do Estado ou mesmo terceiros podem ingressar em habitação alheia sem autorização do morador são limitadas pela Carta Magna às seguintes: a) flagrante delito; b) desastre; c) para prestar socorro; d) por determinação judicial, durante o dia.

Para que não se esvazie o comando contido no artigo 5º, inciso XI, da Carta da República, há de se entender que o flagrante que justifica a invasão de domicílio é apenas aquele que ocorre em situação de emergência.

Roberto Delmanto Junior, em sua obra "As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração", diferencia com perfeição as situações em que se justifica a relativização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, todas elas baseadas no conceito constitucional de emergência e não de flagrante delitivo de crime permanente, até porque o texto constitucional não se apropria deste conceito penal. Transcrevo: "Sem dúvida, a exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar, inclusive em horário noturno e sem determinação judicial, nos casos de flagrante delito, que é disposta ao lado das hipóteses de desastre ou prestação de socorro (art. 5º, XI, 1ª parte) há que ser interpretada sistematicamente, restando patente a intenção do legislador em exigir a configuração de uma verdadeira emergência para que se admita a violação domiciliar, sem determinação judicial, seja ela noturna ou mesmo diurna. Seriam hipóteses, por exemplo, de flagrante de crimes como a extorsão mediante sequestro, em que há necessidade de prestar-se socorro à vítima, que corre perigo de vida etc., o que não se verifica em casos de crimes permanentes como a simples posse de entorpecente ou de armas ilegais. Não havendo esse caráter emergencial, de perigo iminente a um bem jurídico como a vida e a integridade física, a autoridade deverá, sim, obter determinação judicial para invadir o domicílio do suspeito (art. 5º, XI, 2ª parte, da Constituição da República), através da expedição de mandado judicial de busca e apreensão (arts. 240 a 250 do Código de Processo Penal) e não invadir a residência alheia a qualquer hora e sem autorização judicial (o que poderia configurar, inclusive, o crime do art. 150 do Código Penal, dependendo da análise dos incisos I e III de seu §3º, que também devem ser interpretados de acordo com a Magna Carta), sob o pretexto de estar diante de eventual crime permanente, em acusações absolutamente infundadas e, de fato, inexistentes. Por outro lado, justamente para evitar constrangimentos infundados, é que o art. 243 do nosso estatuto processual exige o preenchimento de uma série de pressupostos para a expedição de mandado de busca e apreensão. Poder-se-ia dizer que esse entendimento poderia obstaculizar muito a ação policial; todavia este é um preço pequeno que se paga por vivermos em um Estado liberal e democrático de direito, que sempre deve tomar todas as medidas para restringir, ao máximo, a possibilidade de arbítrios e desmandos das autoridades policiais, por mais bem-intencionadas que possam elas estar." (Obra supracitada, Ed. Renovar, 2ª Edição, 2001, páginas 107/108).

Na hipótese, como não havia perigo iminente a terceiros e nem risco de a prova ser danificada, modificada ou destruída, não havia justificativa razoável para o ingresso forçado na residência do acusado, restando claro que a busca realizada pelos policiais foi abusiva e ilegal, sendo inaceitável a prova produzida a partir deste ato.

Conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, é ônus do Estado comprovar que houve autorização dos moradores para ingresso no domicílio ou que havia justa causa para acesso à residência do acusado sem ordem judicial. Da mesma forma, devem comprovar os fatos que alegam na comprovação das fundadas razões. Tem-se, assim, que o ingresso na residência do réu se deu em desconformidade com a garantia do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A esse propósito, deve-se frisar que, não obstante seja permitida a busca pessoal independentemente de mandado judicial (CPP, art. 244), a busca domiciliar somente poderá ser realizada quando o ingresso na residência seja legítimo, isto é, com

"[...] o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial." (CF, art. 5º, XI). Com efeito, nos termos do art. 241 do Código de Processo Penal, "Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado". Todavia, ainda que tal dispositivo pareça autorizar a busca domiciliar sem a prévia expedição do mandado de busca e apreensão, é certo que não foi ele recepcionado pela atual Constituição Federal, cujo art. 5º, XI, estipula que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Sendo assim, é inquestionável que houve violação ao domicílio do acusado (CF, art. 5º, XI), de modo que os autos de exibição e apreensão e de entrega de fls. 07 e 08 são oriundos de uma ilicitude (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157) e, por isso, são imprestáveis para a formação do convencimento judicial.

Da mesma forma, qualquer prova produzida em decorrência de tal apreensão, resta contaminada pela ilicitude, devendo ser desentranhado dos autos e não podendo ser considerado na formação da convicção do juízo (CPP, art. 157, caput).

Portanto, inexistindo provas contra o acusado, eis que a materialidade delitiva foi construída a partir da entrada ilegal no domicílio, o caso é de absolvição com fulcro no artigo 386, inciso V, CPP.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Caso se entenda pela licitude da apreensão da arma, de rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a confissão deve ser reconhecida, ainda que seja apenas a informal.

No mais, ausentes agravantes e outras atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição de pena.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

No mais, o caso comporta a aplicação do art. 44 do CP, motivo pelo qual se requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

MARCELO APARECIDO DE FRANCA, qualificado nos autos, foi denunciado com incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, porque no dia 11 de junho de 2020, por volta das 04h30, na Avenida Raposo Tavares, número 1556, Bairro Vila Cristina, nesta cidade e comarca, possuía e matinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) espingarda sem marca aparente, numeração ilegível, calibre 28, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu mantinha no interior de sua residência a arma de fogo acima descrita.

Ocorre que policiais militares se deslocaram ao endereço para atenderem uma ocorrência versando sobre violência doméstica. Via COPOM, foram informados sobre a posse irregular da arma de fogo.

Indagado pelos policiais, o réu confirmou que possuía a arma no interior da sua residência, a qual foi apreendida por não possuir qualquer documentação (auto de fls. 10 e laudo pericial de fls. 57/60).

A denúncia foi oferecida, sem oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 74), e recebida (fls. 77/78). O réu foi citado (fls. 85) apresentando resposta escrita, na qual alegou que as questões de mérito serão tratadas após a instrução criminal (fls. 89/90).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência virtual (fls. 91/92).

Durante a instrução criminal, foi ouvida 01 testemunha comum.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

A Defesa alegou que a prova é nula, na medida em que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial.

Em recurso extraordinário, assim se manifestaram os Ministros da Corte Suprema:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.

Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a

medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016 - grifei). Assim, mesmo sem mandado judicial, tratando-se o crime de guarda de armamento permanente, os policiais militares tinham a possibilidade de ingresso na residência, desde que houvesse justa causa.

E a justa causa encontra abrigo nos autos.

Como se verifica da prova oral, os policiais foram atender uma ocorrência de violência doméstica e, depois, foram informados pelo Copom que o réu possuía arma de fogo. Nesse momento, ele foi indagado sobre a denúncia e confirmou a existência da arma, de maneira que surgiu aos policiais a certeza da prática delitiva e a ação deles era legal.

Além disso, segundo os policiais militares, o réu autorizou o ingresso na residência e ainda indicou o local onde a arma estava guardada.

2) Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, bem como pelo laudo pericial de fls. 58/60, segundo o qual a arma de fogo apreendida era eficaz para a realização de disparos.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05/06).

Em Juízo, o réu foi decretado revel.

A autoria restou comprovada nos autos, conforme se verifica das provas. Vejamos. Ouvido apenas na Delegacia, o policial militar Gabriel Camilo Ribeiro afirmou que, por volta das 04h30 do dia dos fatos, estava juntamente com seu colega de Campo desempenhando sua função de policial militar. Foram acionados pelo COPOM para se dirigirem ao local dos fatos, para atenderem ocorrência de violência doméstica. No local, ele e seu parceiro fizeram contato com o casal, que informou que houve uma discussão anterior, porém, já tinham resolvido e não queriam registrar a ocorrência. Enquanto conversavam com o casal, o COPOM informou que, segundo denúncia, havia uma arma de fogo na residência. Indagado, o réu afirmou que possuía uma espingarda, que estava sobre os guarda-roupas, franqueando a entrada dele e seu colega, que a localizaram no local indiciado, tratando-se de uma espingarda, calibre 28, sem munição, sem marca aparente, com numeração, porém, ilegível. O proprietário afirmou que a arma pertencia ao seu genitor, que faleceu no ano passado e que não possui registro dela. Deu voz de prisão ao sujeito e o conduziram à Delegacia (fls. 03).

Nesta audiência, o também policial militar Thiago de Campo revelou que o Copom

informou que um indivíduo estava agredindo a esposa. Deslocaram-se ao local. Subiram até a laje, bateram na porta e o réu foi atendê-los. Conversavam com o réu, quando o Copom irradiou que na casa havia uma arma de fogo. Perguntou, então, ao réu, se havia arma de fogo e ele disse que sim, que estava em cima do seu guarda-roupa. O próprio réu os levou ao quarto, onde encontraram a arma em cima do guarda-roupa, embrulhada num tecido. A arma estava desmuniada e não havia munição na casa. Tratava-se de uma espingarda calibre 28, antiga. O réu disse que a arma era do falecido pai dele. O réu não tinha documentação da arma de fogo. A violência doméstica já tinha se acabado, acredita que tenha sido uma discussão entre o réu e a mulher, que já tinha acabado. Quem chamou a Polícia foi a enteada do réu, que não morava ali. Esclareceram ao réu os direitos constitucionais e revelaram que ele poderia negar a entrada dos policiais. Mesmo assim, ele autorizou a entrada deles. Com efeito, a autoria restou comprovada nos autos. O réu, embora tenha permanecido silente na fase policial, em Juízo não compareceu, embora intimado.

Segundo a prova oral, os policiais militares foram acionados para atenderem ocorrência de violência doméstica, no entanto, quando chegaram ao local, o casal já havia se entendido e não quiseram registrar ocorrência. Enquanto atendiam o casal, o Copom avisou que o denunciante teria informado que o réu guardava arma de fogo na sua residência. Então, os policiais o questionaram e ele confirmou a guarda da arma, franqueando o ingresso dos policiais na residência e indicando o local onde o armamento estava, ou seja, sobre o guarda-roupas. A arma, uma espingarda calibre 38, desmuniada e com numeração ilegível, foi encontrada e apreendida, porque o réu não tinha documentação pertinente. O réu alegou que a arma pertencia ao falecido pai.

Nesse sentido, restou claro que o réu estava na guarda da arma e não possuía a documentação legal, caracterizando o delito.

Com efeito, a condenação do réu é de rigor.

Nem se diga que a arma estava desmuniada e, por isso, não representaria perigo algum, pois de acordo com o laudo pericial de fls. 58/60 apesar de não possuir vestígios de disparos, o armamento possuía efetividade lesiva, o que já indica a periculosidade do réu, uma vez que o crime aqui tratado é de mera conduta e de perigo abstrato.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência:

Apelação da Defesa – Porte ilegal de arma de fogo– Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Eficácia da arma de fogo demonstrada em perícia técnica – Consistente depoimento do policial militar responsável pela prisão do acusado e confissão em Juízo – Crime de perigo abstrato – Arma desmuniada que não afasta a tipicidade da conduta – Comportamento que merece repressão estatal, sobretudo porque a arma de fogo poderia ser rapidamente municiada com os cartuchos que o réu transportava – Condenação mantida – Pena fixada em seu patamar mínimo – Impossibilidade de incidência de circunstância atenuante do crime praticado por pessoa com idade superior a 70 anos, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0006275-88.2017.8.26.0318; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/10/2021; Data de Registro: 15/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. Art. 12 da Lei nº 10.826/03. Autoria e materialidade demonstradas nos autos. Apreensão da arma dentro da casa do réu em cumprimento de mandado de busca. Laudo pericial que concluiu pela potencialidade lesiva da arma. Depoimentos uníssonos e coesos dos investigadores responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e consequente prisão do acusado, que se tornou revel em juízo. Atipicidade da conduta. Reconhecimento da insignificância em razão de estar a arma desmuniada. Descabimento. Entendimento pacífico dos Tribunais Superiores de se tratar crime de perigo abstrato a previsão contida no art. 12 da Lei nº 10.826/03, conquanto ressaltado entendimento deste Relator. Dosimetria. Reincidência que deve ser compensada com a confissão espontânea, ainda que prestada na fase inquisitiva, pois utilizada na conclusão da autoria. Regime semiaberto mantido (art. 33, §2º, c, CP). Substituição por pena restritiva de direito.

Sentença reformada em parte. Recurso defensivo provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1500105-21.2019.8.26.0200; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Gália - Vara Única; Data do Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021 - grifei).

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento - Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos dos policiais e da testemunha presencial em consonância com os demais elementos de convicção colhidos - Arma desmuniada - Crime de perigo abstrato - Conduta típica - Condenação mantida - Penas fixadas de acordo com os parâmetros legais - Pena-base elevada em face das circunstâncias do crime - Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma da lei. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0007341-53.2016.8.26.0637; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 25/08/2021)

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INOCORRÊNCIA. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. A conduta de posse de arma de fogo com numeração raspada não está abrangida pela vacatio legis prevista nos art. 30 a 32 da Lei 10.826/03. Precedentes. 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato. O objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante estar a arma de fogo desmuniada. 3. Ordem denegada. (STF - HC 117206 / RJ - Min. CARMEN LÚCIA - Segunda Turma - Julgamento: 05/11/2013).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI 10.826/03. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA FLAGRADA EM 15/12/05. TIPICIDADE DA CONDUTA. NÃOAPREENSÃO DE ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A segurança coletiva é o objeto jurídico imediato dos tipos penais compreendidos entre os arts. 12 e 18 da Lei 10.826/03, com os quais visa o legislador, mediatamente, proteger a vida, a integridade física, a saúde, o patrimônio, entre outros bens jurídicos fundamentais. 2. Consoante o firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tais crimes são de perigo abstrato, do que se conclui ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado. 3. Por conseguinte, é irrelevante a não apreensão de arma de fogo para o reconhecimento da tipicidade da conduta de posse ilegal de munição de uso restrito, prevista no art. 16 do Estatuto do Desarmamento. Precedentes do STJ. 4. As condutas do art. 16 da Lei 10.826/03 (posse ou porte de arma de fogo de uso proibido) flagradas após 23/10/05 não estão acobertadas pela hipótese de 'atipicidade momentânea', razão pela qual o prazo do art. 30 da Lei 10.826/03, com redação dada pela Lei 11.706/08, a elas não se refere. 5. Ordem denegada" (STJ, Habeas Corpus nº 108.604/DF, 5ª T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 03.03.2009).

"APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato - Condenação mantida. O fato da arma estar desmuniada ou ser antiga não afasta a tipicidade da conduta, se é apta à realização de disparos. Recurso não provido." (TJSP - Apelação nº 0015350-76.2010.8.26.0099 - Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda - Comarca: Bragança Paulista - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 10/03/2014).

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu possui maus antecedentes (Certidão de fls. 63/64 - Processos nº 0016723-61.2007.8.26.0451 e 1542373-50.2018.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: detenção de 01 ano e 02 meses e 11 dias-multa. Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, diante da primariedade

técnica.

Pena final: detenção de 01 ano e 02 meses, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR MARCELO APARECIDO DE FRANCA, qualificado nos autos, nas penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de detenção de 01 ano e 02 meses, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, diária mínima.

O réu é tecnicamente primário e o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, de forma que tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo.

O réu está em liberdade e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

PELA DEFESA TÉCNICA FOI DITO QUE NÃO TEM INTERESSE EM RECORRER DA R.SENTENÇA.

Pelo(a) defensor(a) foi requerido vista dos autos após a intimação do(a) ré(u) do teor da r.sentença.

Pelo(a) MM.Juíz(a) foi dito o seguinte:

Defiro o requerido, devendo a serventia providenciar a vista dos autos à Defensoria Pública, após a intimação do(a)(s) ré(u)(s) do teor da r.sentença.

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):